

<제2장 취소소송의 대상적격.제2절 처분>

I. 처분의 의의

1. 정의[행소법 제2조 제1항 제1호]

- 행정소송법 제2조 제1항 제1호에 따르면 처분이라 함은 행정청이 행하는 구체적 사실에 관한 법집행으로서의 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말한다. 처분은 취소소송의 대상적격을 정하는 가장 핵심적인 개념이며, 행정작용의 다양성을 포괄하기 위해 공권력 행사라는 본질적 요소와 함께 그 밖에 이에 준하는 행정작용이라는 보충적 요소를 규정하고 있다. 따라서 처분으로 인정되기 위해서는 행정청의 작위가 국민의 권리 의무에 직접적으로 영향을 미치는 대외적 효력을 가져야 한다. 국민의 권리 의무에 아무런 변동을 초래하지 않는 행위는 처분성이 부정된다.

2. 처분 개념의 논쟁★

(1) 문제점

- 행정처분은 실체법상 개념으로 강학상으로는 행정행위라는 용어가 사용되고 있다. 처분과 행정행위를 같은 개념으로 보는 견해(실체법상 개념설 또는 일원론)와 처분을 행정행위보다 넓은 개념으로 보는 견해(쟁송법상 개념설 또는 이원론)로 나뉘는데, 논의의 실익은 사실행위를 취소소송을 통해 다룰 수 있는지 여부이다.

(2) 학설

① 실체법상 개념설(일원론)(판례)

- 쟁송법상 처분 개념을 강학상 행정행위와 동일하게 보는 견해로, 취소의 대상은 공권력을 가지는 법적 행위인 행정행위에 한정된다. 따라서 사실행위는 처분에 해당하지 않아 대상적격을 충족하지 못한다.

② 쟁송법상 개념설(이원론)

- 국민의 권리구제 확대를 도모하기 위하여 쟁송법상 처분 개념을 실체법상 행정행위는 물론, 국민의 권익에 영향을 미치는 사실행위 등도 포함하는 광의의 개념으로 보는 견해이다.

(3) 판례

- 판례는 기본적으로 강학상 행정행위를 항고소송의 주된 대상으로 보고 있다. 다만, 권력적 사실행위라고 보이는 단수조치, 교도소 이송조치 및 제소자에 대한 지속적 감시행위에 대하여 처분성을 인정하였고, 비권력적 사실행위인 국가인권위원회의 성희롱 결정에 따른 시정조치를 성희롱 행위자로 결정된 자의 인격권에 영향을 미침과 동시에 공공기관의 장 또는 사용자에게 일정한 법률상 의무를 부담시키는 것이라는 점을 이유로 처분에 해당한다고 하여 처분개념을 확대하고 있다.

(4) 검토

- 처분 개념의 정의규정이나 입법취지, 국민의 권리구제의 실효성 등을 고려하면 현행 행정소송법상 처분을 행정행위보다 넓은 개념으로 보는 쟁송법상 개념설(이원론)이 타당하다고 판단된다.

II. 처분 개념의 분설

1. 행정청의 행위

- 처분은 행정청이 행하는 행위여야 한다. 행정청이라 함은 국가나 지방자치단체 등의 행정주체를 위하여 대외적으로 의사를 결정하고 표시할 권한을 가진 기관을 의미한다. 따라서 단순한 보조기관의 행위나 내부적인 절차 행위는 원칙적으로 처분성이 부정된다. 다만, 법률에 의해 공무를 위탁받은 사인 등의 행위도 그 작용의 대외적 효력 발생 여부에 따라 처분으로 인정될 수 있다.

2. 구체적 사실에 관한 행위

- 처분은 불특정 다수인을 대상으로 하는 일반적 추상적인 법규범 제정이 아닌, 특정인이나 특정 사건에 관한 규율로서 구체성을 가져야 한다. 일반적 규율인 법령이나 조례 등의 제정 행위는 원칙적으로 처분성이 부정되지만, 비록 일반적인 형식을 취하더라도 그 규율의 대상과 내용이 사실상 특정되어 집행 행위의 개입 없이 직접적인 법률효과를 발생시키는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정된다.

3. 법집행의 행위

- 처분은 법률 등 법규범의 규율을 구체적 사실에 적용하여 실현하는 법집행의 행위여야 한다. 이는 행정청의 작위가 자의적이어서는 안 되며, 반드시 법적 근거를 가지고 법률우위의 원칙을 준수해야 함을 의미한다. 이러한 특성은 처분의 위법성 심사가 법규범의 적합성 여부를 중심으로 이루어짐을 보여준다.

4. 공권력 행사로서의 행위

- 처분은 행정청이 국민에 대하여 우월한 지위에서 일방적으로 명령하거나 강제함으로써 국민의 권리 의무에 직접적인 변동을 초래하는 공권력의 행사여야 한다. 이는 대등한 당사자 지위에서 이루어지는 공법상 계약 등과는 구별되는 핵심 요소이다. 공권력의 행사에는 명령이나 강제 등 침익적 작용 뿐만 아니라, 국민의 법적 지위를 설정하는 형성적 작용도 포함된다.

5. 소극적 처분으로서 거부처분

- 행정소송법은 공권력의 행사 외에 그에 대한 거부 역시 처분으로 규정한다. 거부처분이 처분으로 인정되기 위해서는 두 가지 요건이 충족되어야 한다. 첫째, 국민이 행정청에 특정 행위를 신청할 수 있는 법규상 또는 조리상의 신청권이 있어야 하며, 둘째, 그 거부 행위가 신청인의 권리·의무에 직접적인 영향을 미쳐야 한다. 이러한 신청권이 결여된 상태에서의 거부 행위는 단순한 사실적 응답에 불과하여 처분성이 부정된다.

6. 그 밖에 이에 준하는 행정작용

- 행정소송법이 규정한 그 밖에 이에 준하는 행정작용은 전통적인 행정행위 개념으로는 포괄하기 어려운 다양한 행정작용을 사법 심사의 대상으로 포섭하려는 취지이다. 이는 행정작용의 형식에 구애받지 않고 실질적으로 국민의 권리 의무에 직접적인 법률적 효과를 발생시키는 모든 행정작용을 의미하며, 판례는 이 규정을 근거로 처분 개념의 범위를 확대하여 권력적 사실행위 등의 처분성을 인정하는 데 활용하고 있다.

III. 처분 해당 여부의 구체적 검토

1. 의회의 의결

- 지방자치단체 의회의 의결은 원칙적으로 법규 제정 작용 또는 내부적 의사 결정 과정에 해당하여 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 처분성이 부정된다. 그러나 예외적으로 의회 의결 자체가 특정인의 법적 지위를 직접적으로 규율하고 변동을 초래하는 경우에는 처분성이 인정된다. 예를 들어 지방 의회 의원에 대한 징계 의결은 해당 의원의 권한 행사에 직접 영향을 미치므로 처분으로 본다.

2. 법령·조례·고시

- 법령이나 조례 등 일반적 추상적 법규범은 원칙적으로 처분성이 부정된다. 다만, 고시 등이 비록 일반적인 형식을 취하고 있더라도, 그 내용이 집행행위의 개입 없이 직접적으로 국민의 권리 의무 관계를 규율하는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다. 판례는 특정 고시가 행정처분의 기준을

정하여 재량권을 제한하거나 법률의 위임 범위 내에서 법규 사항을 보충하는 경우 처분성을 인정한 바 있다.

3. 중간행위

- 중간행위는 최종적인 처분이 있기 전의 예비적이거나 절차적인 행위로서, 원칙적으로 그 자체만으로는 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 처분성이 부정된다. 예를 들어 사전 결정이나 내부적인 심사 결과 등은 최종 처분을 통해서만 대외적 효력을 발생시킨다. 다만, 중간행위가 후행 처분의 전제가 되어 사실상 국민의 법적 지위에 직접적인 불이익을 초래하여 돌이킬 수 없는 영향을 주는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정되기도 한다.

4. 일반처분

- 일반처분은 특정인이 아닌 불특정 다수인을 대상으로 하지만, 특정 장소나 사건에 관한 규율로서 구체성을 가지므로 처분성이 인정된다. 예를 들어 특정 도로 구간의 통행 금지 처분 등은 그 대상이 불특정 다수일 지라도 내용이 구체적인 사실에 관한 법집행이므로 취소소송의 대상이 된다. 일반처분은 처분의 구체성을 인정하는 데 있어 그 대상의 특정성을 요하지 않는다는 특징이 있다.

5. 행정계획

- 행정계획은 장래의 일정 목표를 설정하고 그에 따른 수단을 종합적으로 조정하는 작용으로서, 원칙적으로 처분성이 부정된다. 그러나 도시 관리 계획 결정 등과 같이 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미쳐 법적 구속력을 가지는 구속적 행정계획의 경우 예외적으로 처분성이 인정된다. 이러한 계획은 계획 확정 처분으로서 항고소송의 대상이 되며, 계획 재량의 한계를 벗어난 경우 위법으로 판단될 수 있다.

6. 사실행위

- 사실행위는 법적 효과를 목적으로 하지 않고 단순히 사실적인 결과를 가져오는 행위로서, 원칙적으로 처분성이 부정된다. 그러나 행정청이 우월한 공권력을 행사하여 국민의 권리 의무에 직접적인 불이익을 주는 권력적 사실행위의 경우에는 예외적으로 처분성이 인정된다. 예를 들어 단수 단전 조치나 행정 대집행의 고고 등은 국민의 법적 지위에 직접적인 영향을 미치므로 처분으로 본다. 비권력적 사실행위는 처분성이 부정된다.

7. 공시지가결정

- 표준지 공시지가의 결정은 토지 수용 보상액 산정, 각종 조세 부과 등의 기준이 되어 토지 소유자의 법률상 이해관계에 직접적인 영향을 미치므로 처분성이 인정된다. 이는 비록 개별 토지 소유자에게 개별적으로 통지되는 행위는 아니지만, 개별적인 재산권 행사에 중대한 구속력을 발휘하는 준사법적 행위로 인정되기 때문이다. 따라서 공시지가 결정에 위법이 있으면 취소소송의 대상이 된다.

8. 반복된 행위

- 기존 처분과 동일한 내용의 행위를 반복하는 경우, 이는 새로운 처분으로서의 법적 효력이 없으므로 원칙적으로 처분성이 부정된다. 이는 제소기간 규정을 잠탈하거나 법적 안정성을 해치는 것을 방지하기 위함이다. 다만, 반복된 행위가 기존의 처분과 별도로 새로운 법률적 효과를 발생시키거나 이해관계인에게 새로운 권리 의무 관계를 설정하는 경우에는 예외적으로 새로운 처분으로 인정될 수 있다.

9. 조세경정처분

- 조세 부과처분 후 세액을 변경하는 경정처분은 원칙적으로 종전의 부과처분을 흡수하여 소멸시키고 새로운 부과처분으로서의 효력을 가진다. 따라서 납세자는 증액 경정처분인 경우 변경된 경정처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다. 감액 경정처분의 경우에는 변경된 당초처분을 대상으로 다투어야 한다. 경정처분은 종전 처분의 법률관계 전체를 재규율하는 성격을 갖는다.

10. 변경처분

- 행정청이 이미 내린 처분을 사후적으로 수정하거나 변경하는 변경처분은, 당초 처분과 변경처분을 합한 변경 후의 처분이 소송의 대상이 된다. 이는 변경처분이 당초 처분의 효력 범위를 수정하여 국민의 법적 지위에 새로운 변동을 가져오기 때문이다. 다만, 변경처분이 당초 처분의 본질적인 내용을 전부 대체하는 경우 등에는 변경된 처분만이 소송의 대상이 된다.

11. 내부적 행정행위

- 내부적 행정행위는 행정기관 내부에서만 효력을 발생하는 행위로서, 예를 들어 상급기관의 지시나 내부 결재 등이 있다. 이러한 행위는 대외적으로 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 처분성이 부정된다. 따라서 항고소송은 내부적 행정행위 자체를 대상으로 할 수 없고, 반드시 그 내부 행위의 결과로 나타난 대외적인 처분을 대상으로 다투어야 한다.

12. 행정행위의 부관

- 행정행위의 부관(조건, 기한, 부담 등)은 주된 행정행위의 효력을 제한하기 위해 덧붙여진 종된 규율이다. 원칙적으로 부관 자체만으로는 독립된 처분성이 부정되어 주된 행정행위와 함께 다투어야 한다. 다만, 부관 중 부담의 경우 독립된 법률 행위로서의 성격을 가지고 별도의 의무를 부과하는 것으로 보아, 부담만 분리하여 독립된 소송의 대상으로 삼을 수 있다는 것이 판례의 입장이다.

13. 신고

- 신고 행위의 처분성은 신고의 종류에 따라 달라진다. 신고만으로 법적 효과가 완성되는 자기완결적 신고에 대한 행정청의 수리 행위는 단순한 사실 행위 또는 법률 효과를 확인하는 행위에 불과하여 처분성이 부정된다. 반면, 행정청의 수리 여부에 따라 법적 효과 발생이 좌우되는 행정요건적 신고에 대한 행정청의 수리 거부 행위는 국민의 법적 지위에 직접적인 영향을 미치므로 처분으로 인정된다.

14. 그 밖에 처분성이 문제되는 경우

- 이 외에도 처분성이 문제되는 행정작용은 다양하다. 예를 들어 행정지도는 원칙적으로 처분성이 부정되지만, 상대방의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 권력적 행정지도는 처분성이 인정될 수 있다. 또한, 공무원의 인사 발령(직위해제, 강등 등) 중 징계 성격이 강하거나 법률상의 불이익을 초래하는 행위는 처분성이 인정되지만, 내부적 인사 발령(전보 등)은 처분성이 부정되는 것이 일반적이다. 판례는 행정작용이 국민의 법적 지위에 미치는 영향 정도를 종합적으로 고려하여 처분성을 판단하고 있다.

IV. 결론

- 취소소송의 대상적격으로서 처분 개념은 행정소송법상 법적 안정성과 국민의 권리 구제라는 두 가치 사이에서 균형점을 찾는 역할을 수행한다. 현행 법과 판례는 형식적 개념에 얽매이지 않고 실질적으로 국민의 권리 의무에 직접적인 영향을 미치는 법적 효과 유무를 중심으로 처분성을 넓게 인정하는 추세이다. 이는 다양화되는 현대 행정작용에 대한 사법 심사의 필요성을 반영하는 것이며, 개별 사안별로 구체적인 법적 효과 및 침해의 중대성을 면밀히 검토하여 처분성 여부를 판단해야 한다.